

<61회 민사소송법 목차 및 해설>

[총평]

안녕하세요 곽준형 변리사입니다.

시험 치느라 고생하셨습니다. 비도 애매하게 내리다 말다 하는게 제가 시험볼 때 날씨랑 비슷했던 것 같아 5년 전 생각이 새록새록 났습니다.

이번 시험의 특징을 보면 1)중요논점을 기본법리에 따라 풀어내는 스타일이 주를 이루었고 2)판례 사실관계를 그대로 내는 문제보다는 판례의 법리를 이용하여 일부 창작된 사실관계를 풀어내는 문제 비중이 높았으며 3)암기범위를 무작정 늘리기 보단 중요한 것 위주로 강약있는 공부를 하면서 문제풀이 경험을 많이 쌓은 사람이 유리한 시험이었습니다.

문제 난이도는 중하 정도이지만 정해진 내용을 그대로 바르는 문제가 아닌, 다소 낯선 문구들로 이루어진 문제들이라 긴장감 때문에 논점을 헛갈리거나 분량조절미스가 나서 실제 시험에서 실력 발휘를 제대로 못하는 경우도 있었을 것 같습니다.

그래도 큰 산을 하나 넘었고, 주사위는 던져졌으니, 수고한 스스로를 안아주시고 한숨 돌리시면서 휴식을 꼭 취하시기 바랍니다.

목차 및 해설 올려드리니 확인해보시고, 이상한 점이 있으면 홈페이지 QnA 또는 mrtosilson@gmail.com으로 질문주세요. 추가반영할 사항이 있다면 추가반영하도록 하겠습니다.

항상 말씀드리지만 강사의 모범답안은 고득점을 받는 일 실시 예이고, 고득점 답안끼리도 약간씩 차이가 있기 때문에 사소한 부분에서 제가 쓴 답안과 다른 점이 있다고 해서 낙담하지 마시기 바랍니다.

[문제-1]

I. 설문(1)

1. 문제의 소재

2. 재산적 손해 부분의 항소심 이심 여부

(1) 신체상해에 따른 손해배상청구 소송물 - 학판검

(2) 병합 형태 - 단순 병합

(3) 상소불가분원칙 의의 및 취지

3. 소변경 적법성

- (1) 소변경 의의 및 취지 [제262조]
- (2) 청구취지 확장이 소변경인지 여부 - 학판검
- (3) 소변경 요건 - 기절사동공/취원변해

4. 청구취지 확장을 위한 전부승소자의 항소이익 인정 여부

- (1) 항소이익 의의 및 취지
- (2) 항소이익 판단 - 학판검
- (3) 전부승소자의 경우 - 판(목or손)

5. 사안해결

=>재산적 손해 청구취지 5천만 원으로 확장 가능

*** 2번 목차와 3번 목차는 서브논점, 4번 목차는 메인논점, 2번 목차는 분량 많이 작게 써도 무방, 2번 목차는 많이 기재하지 않는 것이 바람직

*** 전부승소자 항소이익에서 목시적 일부청구 사안과 신체상해에 따른 손해배상청구 사안 모두 기판력으로 인해 나머지 부분을 후소로 구할 수 없으므로 청구확장을 위한 항소이익을 인정한다는 법리는 공통되므로 어떤 판례든 확실히 기재해주었다면 ok

II. 설문(2)

- 1. 문제의 소재
- 2. 화해의 의의 및 취지
- 3. 화해의 법적 성질 - 학판검
- 4. 강박을 이유로 화해조서의 무효 주장 가부 - 학판검
- 5. 사안해결

=>화해무효 확인의 소는 받아들여질 수 없음

III. 설문(3)

1. 문제의 소재 – 각서는 사문서이자 처분문서

2. 서증 의의 및 취지

3. 각서의 형식적 증거력 인정 가부

(1) 형식적 증거력 의의

(2) 판단 - 인침부부

(3) 추정 - 제357조, 2단의 추정

(4) 복멸 – 문서의 진정성립 추정 복멸 – 백지문서 보충기재 – 학판검

4. 각서의 실질적 증거력

(1) 실질적 증거력 의의

(2) 판단, 추정, 복멸

5. 사안해결

=>乙이 백지문서였다는 점을 본증으로 법관에게 확신을 주지 않았다면 2단의 추정은 복멸되지 않고 각서의 내용대로 5천만 원 지급 명하는 판결 가능, 하지만, 乙이 백지문서였다는 점을 본증으로 법관에게 확신을 주었다면 2단의 추정은 복멸되고, 甲에게 백지문서 보충할 정당한 권원이 있었다는 점을 甲이 증명하지 않는 한 각서를 증거로 5천만 원 지급을 명하는 판결 불가

*** 백지문서 보충기재 학판검은 분량 너무 길지 않게 기재

[문제-2]

I. 설문(1)

1. 문제의 소재

2. 관할합의 의의 및 취지 [제25조]

3. 관할합의 요건 – 1임법법송/서

4. 관할합의 종류 – 학판검

5. 乙의 주소지 변경에 따른 전속적 합의관할법원 B로 변경 여부

6. 사안해결

=>보통재판적에 따라 계약당시 법정관할지에 해당하는 乙의 주소지 A에 전속적 관할합의 효력이 발생하며, 乙의 개인적인 사정인 이사로 인해 계약성립당시 예정한 관할법원이 A에서 B로 변경되는 것은 부당하므로, 전속적 관할합의에 따라 관할법원이 되는 A에 이 사건 소의 관할권 인정

*** 약관은 일방이 불특정 다수의 고객과의 계약을 예정하여 만들어둔 약정사항이 기재된 문서여야 하므로 동 문제는 약관 문제는 아님

*** 전속적 합의관할에 따른 관할법원이 乙의 이사로 인해 A에서 B로 변경되는 것이 아니라는 논리를 설명하기 위해 약관규제특별법 관련 판례에서 전속적 합의 후 일방의 주소지 변경으로 인해 전속적 합의관할법원이 변경되지는 않는다는 2009마1482판례 제시가 가능하지만, 필수는 아니며, 乙의 주소지 이전으로 인해 전속적 합의관할법원이 변경된다고 보면 일방이 관할법원 지정하는 것과 같은 결과가 되고 甲이 소송을 수행함에 있어 현저한 불편을 갖게 되므로 부당하다고 근거를 들며 A법원이 당초 전속적 합의에 따른 관할법원이라고 써도 됨.

II. 설문(2)

1. 문제의 소재

2. 항소심반소 의의 및 적법성

3 사물관할 및 소가의 의의

4. 내용

(1) 1심은 소가 5억 원 이하는 지방법원 단독판사, 소가 5억 원 초과는 지방법원 합의부

(2) 2심은 1심 단독판사 사건 중 소가 2억 원 이하는 지방법원 합의부, 1심 단독판사 사건 중 소가 2억 원 초과는 고등법원, 1심 지방법원 합의부 사건은 고등법원

5. 소가산정의 표준시기 및 사물관할 위배 여부

(1) 원칙 – 소제기시를 기준

(2) 예외 – 1심에서 청구취지 확장으로 5억 원 초과, 1심에서 합의부 사건(소가 5억 원)에 속하는 반소제기시

(3) 예외의 예외 – 1심에서 청구취지 감축으로 5억 원 이하(당사자에게 불이익이 없고 심리지연 방지 위해), 2심에서 청구취지 확장, 청구취지 감축, 반소제기시(2심은 사물관할이 아닌 심급관할로 정해짐)

6. 사안해결

=>D고등법원으로 이송하지 않음

*** 2번 목차는 분량 매우 작게 쓰거나 생략 가능, 많이 쓰는 건 안됨

[문제-3]

I. 설문(1)

1. 문제의 소재

2. 소변경 적법성

(1) 소변경 의의 및 취지 [제262조]

(2) 소변경 요건 - 기절사동공/취원변해

(3) 소변경 형태 - 추가적 변경

3. 대상청구 병합

(1) 대상청구 의의 및 종류

(2) 주위적 청구의 이행불능 대비 대상청구

(3) 주위적 청구의 집행불능 대비 대상청구

4. 사안해결

=>제2의 소 추가 가능

*** 변론종결시까지 수용되면, 주위적 청구인 소유권이전등기청구는 이행불능이 되고, 대상청구는 이행불능 대비 대상청구로 적법, 변론종결시까지 수용되지 않으면, 주위적 청구인 소유권이전등기 청구의 변론종결 이후 이행불능(집행불능)에 대비한 대상청구로 적법

II. 설문(2)

1. 문제의 소재 - 변론종결시까지 수용 여부가 확정되지 않으면 집행불능 대비 대상청구

2. 장래이행의 소 의의 및 취지

3. 장래이행의 소 요건

(1) 청구적격

(2) 미리청구할 필요

4. 사안해결

=>장래이행의 소이더라도 조건성취 개연성이 있으면 청구적격, 미리청구할 필요 인정되어 제2의 소를 장래이행의 소로 제기할 수 있음

Ⅲ. 설문(3)

1. 문제의 소재 - 두 청구가 모두 인용된 것으로 보아 집행불능 대비 대상청구인 것을 전제

2. 병합형태 - 학판검(현재이행의 소와 장래 이행의 소의 단순병합(판례) 또는 부진정예비적 병합(학설))

3. 제2의 소에 대한 불복으로 제1의 소의 이심 여부

(1) 상소불가분의 원칙

(2) 병합형태를 단순병합으로 보는 경우 상소불가분원칙 적용 여부 - 학판검

4. 불복하지 않은 청구의 확정시기 - 학판검

5. 사안해결

=>제1의 소가 확정되었음을 이유로 소유권이전등기절차 실행 불가

*** 3-(2)번 목차는 분량 다소 줄일 수 있음,

*** 4번 목차는 서브논점, 분량 많이 줄이거나 생략 가능, 많이 기재하지 않는 것이 바람직

[문제-4]

I. 설문(1)

1. 문제의 소재

2. 변론주의 의의 및 내용

(1) 의의 및 내용

(2) 사실주장책임 의의

3. 주요사실 및 간접사실 구별 - 학판검

4. 협의의 소송자료 준별 및 완화

(1) 준별

(2) 완화 - 간묵다

5. 간접적 주장 인정 가부 - 학판검

6. 사안해결

=> 당사자가 甲의 추인을 증명하기 위해 증인신문을 신청하였다는 사정이 없는 한, 증인신문 결과만으로 주장도 하지 않은 甲의 추인을 인정하여 판결할 수 없음

II. 설문(2)

1. 문제의 소재

2. 乙진술의 성격 - 제한부 자백

3. 자백 의의 및 취지, 효과

4. 자백철회 가부

(1) 자백철회인지 여부 - 묵시적 철회

(2) 원칙 - 자백 철회 불가(여효적 소송행위)

(3) 예외 - 5동착경

5. 사안해결

=> 자백 철회사유 없으므로 자백철회 불가

*** 등기의 추정력 기재하면서 무권대리사실은 甲에게 증명책임이 있다라고 짚어줄 수는 있으나, 필수 논점은 아니고, 생략해도 무방

*** 무권대리 증명책임은 甲에게 있으므로 자기에게 증명책임 있는 사실에 대한 자백은 논점 아님